

第2節 中止犯

刑法
№135

H21-6

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCが、中止犯の刑の減免（刑法第43条ただし書）の根拠に関する次のアからウまでの【見解】のいずれかを採って、後記【会話】のとおり議論している。A、B及びCが、それぞれどの【見解】を採っているかを検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- ア. 行為者及び将来犯罪を実行するかもしれない国民一般に対して犯罪の中止を奨励することによって法益を侵害から守ることに根拠を求める見解
- イ. 障害未遂と比べて行為者に対する非難が減少することに根拠を求める見解
- ウ. 自ら生じさせた危険を自ら消滅させたことにより違法性が減少することに根拠を求める見解

【会 話】

学生A. 我が国の刑法では、中止犯は犯罪の成立を妨げる事由とはされておらず、刑の減免しか認められていないし、普通、一般人は、中止犯の規定の存在を知らないだろうから、B君の言う根拠は説得力を欠くのではないか。

学生B. A君の見解によれば、真剣な中止行為が行われる限り、結果が発生した場合でも刑の減免を認めるべきことになるはずだ。ところが、刑法第43条の規定によれば、犯罪が既遂に達した場合には中止犯を認めることができないのであって、現行法の立場とは整合しないという問題があるね。

学生C. その上、A君の見解では、中止犯の成立を倫理的に是認し得る動機による場合に限定するのが自然だが、刑法第43条ただし書にはそんな限定はなされていないよ。

学生A. そうは言っても、C君の見解では、被教唆者が中止行為を行ったときに、教唆者にも刑法第43条ただし書の適用があることになるはずだ。しかし、一般に、中止犯の効果は一身専属的なものだと考えられているから、この点についてC君の見解では適切な説明ができないのではないか。

1. Aア Bウ Cイ
2. Aイ Bウ Cア
3. Aイ Bア Cウ
4. Aウ Bア Cイ
5. Aウ Bイ Cア

中止犯の刑の減免(43条ただし書)の根拠には政策説(見解ア)と法律説(責任減少説(見解イ)と違法減少説(見解ウ))の対立がある。以下、各学生と見解の組合せについて検討する。

学生A イ

学生Bは、学生Aの見解に対し、「犯罪が既遂に達した場合には中止犯を認めることができないのであって、現行法の立場とは整合しないという問題がある」と批判している。この批判が妥当する見解は、責任は犯罪の実行を決意した意思に対する非難可能性であるから、その決意を撤回した以上非難可能性は減少するとし、あるいは中止行為によって新たに規範的人格態度が形成されることになるから、非難可能性は減少ないし消滅するとする責任減少説である。この説に従うと、決意の撤回ないし中止行為がなされた以上非難可能性は減少ないし消滅することとなるから、未遂に終ろうと既遂に達するとを問わず中止犯が認められ、未遂犯にのみ中止犯を認める刑法の解釈としては妥当でないとの批判がある。また、学生Cは、学生Aの見解に対し、「中止犯の成立を倫理的に是認し得る動機による場合に限定するのが自然だが、刑法43条ただし書にはそんな限定はなされていない」と批判している。この批判が妥当する見解も責任減少説である。すなわち、責任減少説が、倫理的な要因を責任減少の根拠にすることは、悔悟を要件としない現行法とは相容れないという批判がある。したがって、学生Aの見解は責任減少説であり、これに対応する見解はイである。

学生B ア

学生Aは、第1発言において、学生Bの見解に対し、「我が国の刑法では、中止犯は犯罪の成立を妨げる事由とはされておらず、刑の減免しか認められていないし、普通、一般人は、中止犯の規定の存在を知らない」と批判している。この批判が妥当するのは、犯罪の実行に着手した者についても、「後戻りのための黄金の橋」を架けることにより、最後の瞬間まで中止を期待し、奨励し、もって法益を保護しようとする趣旨であるとする政策説である。政策説に対しては、一般人は必ずしも中止行為の恩賞を知るものではなく、また、その恩賞も、不可罰とするならばともかく、単に刑の必要的減輕又は免除にすぎない我が国では効果が薄いなどの批判がなされている。したがって、学生Bが採っている見解は政策説であることが分かり、これに対応する見解はアである。

学生C ウ

学生Aは、第2発言において、学生Cの見解に対し、「被教唆者が中止行為を行ったときに、教唆者にも刑法第43条ただし書の適用があることになるはずだ」が、「一般に、中止犯の効果は一身専属的なものだと考えられているから、この点についてC君の見解では適切な説明ができない」と批判している。この批判が妥当する見解は、事後に故意を放棄し、あるいはみずから結果の発生を防止した場合は、結果発生の現実的危険及び行為の反社会的相当性を事後的に減少させるものとして、違法性を減少させることとする違法減少説である。違法減少説に対しては、違法性は連帯するから中止未遂は他の共犯者にも連動することとなるため、中止していない共犯者も不可罰とせざるを得なくなり、中止未遂のもつ一身専属的な効果に反することとなるという批判がある。したがって、学生Cの見解は違法減少説であることが分かり、これに対応する見解はウである。